

1500141-44.2020.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA ESSER DE SOUZA

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas- Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 1. PRELIMINAR - Nulidade decorrente de prisão efetuada por guardas civis - Descabimento - Nota-se, em primeiro lugar, que se trata de crime de tráfico ilícito de drogas, delito de natureza permanente - Ademais, qualquer pessoa pode realizar a prisão em flagrante, bem como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

2ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, nº 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500141-44.2020.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500141-44.2020.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2043680/2020 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 10044479 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 277/2020 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2043680 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 277/20/210 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO PEDRO GIACOMELLI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA ESSER DE SOUZA

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra JOÃO PEDRO GIACOMELLI, brasileiro, solteiro, RG nº 55736726 SSP/SP, CPF 444.595.598-11, nascido em 27/07/2000, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Antônio Fernando Giacomelli e de Sandra Regina Santos Giacomelli, residente na Alameda das Bromélias, nº 302, Residencial Primavera, Maracáí/SP, como incurso no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pela prática, em tese, dos seguintes fatos:

Consta, dos inclusos autos que, no dia 14 de fevereiro de 2020, por volta de 15h24, na Rua Maria Ferrini Molina, nº121, Vila Maria Zélia, nesta cidade e Comarca de Pirapozinho, JOÃO PEDRO GIACOMELLI, qualificado às fls. 04/05, guardava e tinha em depósito, 7 (sete) porções de maconha, com peso líquido de 21,4g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 10/11) e auto de constatação preliminar de substância entorpecente

(fls. 15/16).

Conforme o apurado, o denunciado guardava e tinha em depósito as drogas acima mencionadas no interior de sua residência.

Apurou-se que, no dia dos fatos, policiais foram informados via COPOM que o denunciado estava comercializando drogas próximo à sua residência, e para lá se dirigiram.

No local, encontraram o denunciado e procederam uma revista pessoal, mas nada de ilícito foi localizado. No entanto, o denunciado informou aos policiais que havia umas “bacinhas” em sua residência.

Assim, os policiais realizaram busca na residência do denunciado e encontraram no quarto dele, sobre o guarda-roupas, um saco plástico contendo 07 (sete) porções de maconha, que estavam fracionadas. No local, também foi apreendida a quantia de R\$63,00 (sessenta e três) reais.

O denunciado confirmou na presença de seu advogado que estava traficando a droga para obter dinheiro para suas despesas, bem como para sustentar o seu vício.

Assim, as circunstâncias em que se deram os fatos, notadamente a informação que o Denunciado estava comercializando drogas, a quantidade de droga apreendida, a maneira como estavam acondicionadas, bem como a confissão do Denunciado na Delegacia de Polícia, não leva a ideiação outra senão a de que as drogas encontradas destinavam-se efetivamente ao consumo de terceiros, isto é, ao tráfico de drogas.

O réu foi preso em flagrante e em audiência de custódia foi beneficiado com liberdade provisória cumulada com medidas cautelares (fls. 41/43).

A denúncia foi oferecida em 02/04/2020 (fls. 85/87) e no dia 22/04/2020 foi determinada a notificação do acusado para apresentação de defesa prévia (fl. 88).

O réu foi notificado em 26/10/2021 (fl. 154) e a defesa prévia foi apresentada em 08/02/2022, por meio de defensor nomeado (fls. 159/160).

A denúncia foi recebida em 12/04/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 163/165).

No curso do processo o acusado constituiu advogado (fls. 202 e 213).

Na audiência realizada em 29/07/2022 foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e foi o réu interrogado. Na oportunidade, o Ministério Público apresentou alegações orais, pugnando pela condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 207/208).

Em memoriais, a defesa arguiu preliminar de nulidade por violação de domicílio e por violação da advertência do direito ao silêncio por ocasião da prisão em flagrante. No mérito, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para uso pessoal ou, em caso de condenação, que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, com fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 216/253).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, analiso as preliminares arguidas pela defesa.

Não merece acolhimento a tese de ilicitude da prova por violação de domicílio.

No caso em tela, tanto quando ouvidos na Delegacia de Polícia, quanto em Juízo, os policiais militares foram uníssomos ao informarem que foi o próprio réu quem franqueou a entrada em sua residência e, ainda, confirmou que possuía substâncias entorpecentes dentro do imóvel, o que também foi confirmado pelo réu em seu interrogatório em solo policial (fl. 04). Destaque-se que na ocasião o acusado foi interrogado na presença de seu advogado (Dr. Luís Otávio Forti). Agora, em evidente comportamento contraditório, instruído por advogado diverso, contratado no decorrer do processo, o réu nega ter dado autorização; essa alegação, entretanto, não merece qualquer credibilidade, porquanto isolada no conjunto probatório e em total contradição com o que por ele próprio dito em momento anterior.

Ainda que autorização não houve – o que, ressalto, não é o caso dos autos – sobre o assunto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603616/R0, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem

que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". (grifei)

E na hipótese foi constatado que dentro da casa havia situação de flagrante delito, eis que os policiais foram levados até o local por meio de denúncias anônimas que reportavam o tráfico de drogas por JOÃO PEDRO, e dentro da casa dele foram encontradas as substâncias entorpecentes, conforme abaixo será visto, já embaladas para venda.

A própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, ao dispor acerca do direito fundamental à inviolabilidade domiciliar, excepciona os casos de flagrante delito.

Logo, não há qualquer ilegalidade na conduta dos policiais, seja porque ingressaram na residência do réu após autorização deste, seja porque havia situação de flagrante delito no interior do imóvel, não havendo que se falar, por conseguinte, em nulidade do feito por ilegalidade de provas.

Sobre o assunto, para ilustrar, trago à baila os seguintes julgados do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas– Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 1. PRELIMINAR – Nulidade decorrente de prisão efetuada por guardas civis – Descabimento - Nota-se, em primeiro lugar, que se trata de crime de tráfico ilícito de drogas, delito de natureza permanente – Ademais, qualquer pessoa pode realizar a prisão em flagrante, bem como as autoridades devem assim proceder – Não se vislumbra qualquer exceção à atuação de guardas municipais, integrantes dos quadros de força pública no âmbito municipal – -Prova ilícita em razão de invasão de domicílio – Não cabimento – Em se tratando de crime de tráfico ilícito de drogas, delito de natureza permanente, a ausência de mandado não macula a busca e apreensão (...) (TJ-SP - APR: 15014712820208260599 SP 1501471-28.2020.8.26.0599, Relator: Silmar Fernandes, Data de Julgamento: 21/06/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/06/2021)

HABEAS CORPUS – nulidade por adentrarem os policiais na residência do réu sem mandado – tráfico na modalidade "guardar" é crime permanente – desnecessidade de mandado – fundada suspeita configurada – indefere-se o processamento. (TJ-SP - HC: 20429225620228260000 SP 2042922-56.2022.8.26.0000, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 16/03/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/03/2022)

Assim também decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente:

"(...) VI - No caso, a entrada dos policiais na propriedade dos pacientes se deu após "abordagem aos acusados Kevin e Denis, com os quais foram encontrados dinheiro e drogas, e, ainda, que a própria corré Stefannie de Souza Moreira teria revelado aos policiais o local onde estariam armazenadas as substâncias ilícitas". Assim, é certo que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio, não havendo que se falar em ofensa à sua inviolabilidade no cumprimento da medida. (...) (STJ - AgRg no RHC: 141113 SP 2021/0005567-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2021)

Melhor sorte não assiste à defesa ao alegar nulidade por violação do direito constitucional ao silêncio por ocasião da prisão em flagrante.

A despeito do esforço defensivo, o caso concreto não se amolda ao conceito de interrogatório sub-reptício, caracterizado quando a autoridade se vale de subterfúgios ilícitos para obter esclarecimentos sobre os fatos em apuração. Nessas ocasiões, ignoram-se todas as formalidades contidas nos arts. 6º e 185, ambos do Código de Processo Penal, nas quais está incluído o princípio da não autoincriminação, refletido no direito ao silêncio e, principalmente, na advertência do réu quanto à sua existência.

In casu, extrai-se do interrogatório extrajudicial do acusado (fl. 04), a advertência acerca do direito de permanecer calado, em estrita observância ao disposto no ordenamento jurídico. Outrossim, não se vê nos autos quaisquer indícios de emprego de mecanismos ilícitos visando a colheita de declarações diretas do réu

quanto à autoria delitiva; pelo contrário, ele foi interrogado, em solo policial, na presença de advogado, tendo todos os seus direitos resguardados.

Ademais, ainda que os policiais tenham reproduzido os esclarecimentos prestados pelo acusado no momento do flagrante, há de se ter em conta que, em Juízo, foram ouvidos como testemunhas, portanto prestaram o compromisso legal de dizer a verdade, sendo certo que os depoimentos dos agentes da segurança pública gozam de presunção de veracidade, constituindo, por isso, elementos de convicção válidos, especialmente, como no caso em tela, se não existirem evidências de que tivessem motivos escusos para imputar a prática delitiva a um inocente.

Não bastasse, cediço que eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante não maculariam a ação penal.

Pelo acima exposto, rejeito as preliminares.

Passo ao exame do mérito.

A materialidade do fato restou devidamente comprovada nos autos pela reunião dos elementos sensíveis do crime, em especial o Auto de Prisão em Flagrante; o Boletim de Ocorrência (fls. 07/09); o Auto de Exibição/Apreensão (fls. 10/11); os laudos periciais (fls. 57/60 e 61/75).

Quanto à autoria, necessária análise pormenorizada do conjunto probatório.

Interrogado na Delegacia de Polícia, na presença de advogado, o acusado confessou o crime de tráfico de drogas, afirmando que "estava próximo a sua casa fumando um baseado pois é usuário de drogas (maconha); após revista foi encontrado apenas uma "baranga" e então os policiais o conduziram até sua residência onde autorizou a entrada dos policiais; como os policiais estavam demorando o declarante contou a eles que havia entorpecentes em cima do seu guarda-roupas, dentro do seu quarto, ao que eles confirmara a presença do entorpecente; o interrogando informou que adquiriu o entorpecente na cidade de Pres. Prudente, de um "nóia", na semana passada para seu uso, mas teve que traficar para levantar dinheiro para suas necessidades e sustentar seu vício; o dinheiro encontrado com o interrogando se deve a mercância do respectivo entorpecente." (fls. 04/05)

Em juízo, porém, instruído por advogado diverso, JOÃO PEDRO alterou sua versão dos fatos, passando a negar o comércio de entorpecente, tendo alegado que na data dos fatos desceu na casa de seu colega para jogarem baralho, e lá foi abordado pelos policiais, que revistaram a casa do menino, mas não acharam nada, então o algemaram e o levaram para sua casa. Negou ter autorizado que os milicianos adentrassem sua residência, porém, confirmou ter informado aos policiais que possuía umas "baguinhas", por ser usuário, e que elas estava em cima do guarda roupas. Disse ter comprado a droga em Presidente Prudente, no Parque do Povo, e ganhou os saquinhos vazios para levar a droga consigo quando saísse, para não configurar tráfico caso fosse abordado. Alegou ter sido ameaçado pelos policiais, especialmente o policial Gossi, aduzindo que ele ficava engatilhando a arma falando que iria chamar o policial Ferreirinha caso não confessasse, sendo esse Ferreirinha conhecido por "judiar da molecada na rua". Confirmou ter, de fato, prestado o depoimento constante à fl. 04, tal como lá descrito, todavia, não sabia que o advogado era ex-Delegado de Polícia, tendo ele o orientado que se confessasse, iria sair da prisão. Alegou que não arrolou o menino que teve a casa vistoriada inicialmente porque ele não foi localizado por sua irmã, que ficou encarregada de ir atrás. Quanto à mensagem em que faz uma cobrança a uma pessoa, verificada em seu aparelho celular, alegou que essa cobrança se referia ao valor de R\$ 50,00 que havia emprestado a seu conhecido no bar. Alegou que já havia terminado o depoimento na Delegacia quando o advogado chegou e nada disse na audiência de custódia a respeito dessas irregularidades porque havia policiais ali para judiarem-no.

O Policial Militar Marcos Antônio Gossi, por seu turno, relatou que no dia dos fatos o COPOM recebeu a ocorrência de tráfico de drogas porque o indivíduo Joao Pedro estava traficando, então saíram em diligências e abordaram o acusado, porém, com ele nada foi encontrado, e em entrevista ele disse que tinha droga em casa, que estava traficando, possuía R\$ 63,00 no bolso e na casa dele havia mais; então adentraram a residência, com a autorização dele, e em cima do guarda roupas encontraram porções de maconha, tendo o réu confessado os fatos e informado que os R\$ 63,00 que estavam com ele eram provenientes do tráfico. Disse não se recordar

quem algemou o acusado, nem se ficou o tempo todo dentro da casa, mas acredita que não; também não se recorda quem deu voz de prisão e, pelo que se recorda, não havia abordado o acusado antes dos fatos. Disse que o dinheiro não foi encontrado dentro da casa, mas sim no momento da abordagem, e confirmou que o réu disse que a droga era para venda. Esclareceu que da primeira abordagem até a casa do réu dava uns 50 metros. Por fim, elucidou que João Pedro confirmou a traficância antes de encontrarem a droga, ao dizer que possuía mais na casa dele, e que em nenhum momento ele falou que a droga era para uso.

No mesmo sentido narrou o Policial Militar Alã Junior dos Santos, ao relatar que receberam denúncias de tráfico, e de posse das características do indivíduo se deslocaram ao local e encontraram o acusado nas proximidades, tendo ele demonstrado nervosismo quando se aproximaram, então perguntaram se ele estava traficando drogas ali, tendo ele respondido que possuía algumas porções na casa dele. Contou que entraram na residência com autorização do réu e encontraram diversas porções de maconha sobre o guarda roupas, em embalagens plásticas, e com o acusado encontraram R\$ 63,00 em notas picadas. Segundo o Policial, João Pedro disse que havia comprado a droga em Presidente Prudente e iria vendê-la para levantar um dinheiro.

Esclareceu que a abordagem foi realizada uns 50 metros da residência, e que nesse momento, com o réu havia mais um indivíduo, porém, como na denúncia anônima foi citado o nome de João Pedro, com a informação de que ele estaria na posse de entorpecentes, perguntaram se na casa dele havia mais drogas, e ele disse que sim. Informou que foram apenas na residência do réu, não adentraram outra residência antes, e alegou não se recordar se o dinheiro estava na posse dele ou na residência. Informou, ainda, que a central já havia emitido vários alertas de que João Pedro estava traficando drogas pelo bairro e que não realizaram campanhas antes, porque quem faz isso é a Polícia Civil. Explicou que na casa do réu encontraram material para endolação, pequenas embalagens plásticas idênticas àquelas nas quais foram encontradas as pequenas porções, e disse que deram voz de prisão ao réu no momento em que encontraram a droga e que ele confessou que estava traficando. Esclareceu, ainda, que João Pedro acompanhou a busca na residência durante todo o momento e disse que no momento da prisão todos os direitos são lidos ao réu.

Verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais em Juízo estão em perfeita consonância com o que por eles informado na Delegacia de Polícia, por ocasião da prisão em flagrante (fls. 02/03).

Ao contrário do que alegado pela defesa em suas alegações finais, não se verifica qualquer contradição nos depoimentos dos milicianos, que foram claros e harmônicos entre si; diferente do que ocorre com o réu, que num primeiro momento confessou a prática delitiva e, na fase judicial, voltou atrás e passou a negar os fatos, inclusive trazendo outros elementos antes não mencionados e que não foram minimamente comprovados, como a falta de autorização para ingresso na residência, a busca domiciliar realizada em residência de terceiro antes de ingressarem na residência do réu.

Força demais a defesa, para não se dizer que age com má-fé, ao buscar retirar a credibilidade do trabalho do advogado que acompanhou o acusado na Delegacia de Polícia. O fato de o advogado ter sido Delegado de Polícia em nada interfere em seu trabalho na defesa de seu cliente; qualquer alegação em sentido contrário deve ser devidamente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a defesa (art. 156, CPP). Enfim, o conjunto probatório é vasto, firme e suficiente para ensejar um decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, porquanto as denúncias anônimas que reportavam o comércio de drogas pelo réu – ressalte-se que, segundo os policiais, as denúncias mencionavam o nome de João Pedro – restaram confirmadas com a apreensão das porções de maconha, totalizando 21,4 gramas, e com a confissão do próprio réu, na Delegacia de Polícia, no sentido de que vendia a droga para a manutenção de seu próprio vício, e que o dinheiro consigo apreendido era proveniente do tráfico de entorpecentes.

Neste ponto, observo que embora tenha alegado que recebia ajuda da irmã e da mãe, e que trabalhava com material reciclável, de modo a poder arcar com o pagamento do aluguel e, inclusive, com o sustento de seu vício, cabia à defesa fazer prova nesse

sentido; poderia ter arrolado a mãe e a irmã de João Pedro como testemunhas para comprovação dessa alegação, mas assim não fez.

Acrescente-se, ainda, que as porções de maconha estavam embaladas individualmente, em saquinhos zip, prontas para venda, e que foram encontrados saquinhos idênticos na residência de João Pedro, ainda sem uso, ficando evidenciado que era ele quem fracionava e embalava as porções para comercialização, não sendo crível a alegação de que o traficante, de quem o acusado teria comprado a droga, tenha fornecido também os saquinhos vazios.

E a perícia realizada no aparelho celular do acusado constatou mensagem de cobrança enviada por João Pedro ao contato "Guardinha" (fl. 71). Analisando a mensagem em cotejo com o conjunto probatório, resta evidente que a cobrança dizia respeito à venda de entorpecente. O réu alegou que era referente ao empréstimo de R\$ 50,00 àquela pessoa, contudo, porque também não a arrolou como testemunha para comprovar sua versão? Ao que tudo indica, por ser inverídica.

Por todo o exposto, não restam dúvidas de que as porções de maconha apreendidas na residência do acusado eram destinadas à comercialização, incidindo, portanto, nas disposições do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, porque patente o tráfico de drogas.

Ademais, a condição de usuário não ilide a de traficante, tendo em vista ser bastante comum que o usuário comercialize drogas para o sustento do próprio vício, o que se verifica no caso em tela.

Logo, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como as circunstâncias em que se deu a prisão, não se coadunam com a de simples usuários de drogas.

No que concerne à tipicidade, vale salientar que JOÃO PEDRO faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Para que haja a incidência da benesse é necessário o preenchimento de quatro requisitos, cumulativos: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar às atividades criminosas; e, (d) não integrar organização criminosa.

In casu, analisando a Folha e a Certidão de antecedentes criminais carreadas aos autos (fls. 37 e 38), verifica-se que o réu é primário, tendo sido esta sua primeira passagem policial.

Além disso, não há provas de que o viesse se dedicando a atividades criminosas, nem de que integrasse organização criminosa, sendo o tráfico objeto deste processo, até então, o primeiro envolvimento criminal de sua vida.

Todavia, a minorante deve ser aplicada em seu grau intermediário (1/2), tendo em vista que mesmo após sua prisão neste feito o acusado continuou a delinquir, vindo a ser preso pelo delito de tráfico de drogas perante o Juízo de Maracá/SP (fls. 187/188), inclusive encontrava-se preso por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada em 29/07/2022.

A propósito do tema, vale salientar que o magistrado possui discricionariedade para o estabelecimento do grau de redução da pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU MÁXIMO (2/3). INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ORDEM DENEGADA. I - As instâncias ordinárias não deixaram de justificar a aplicação da causa de diminuição em seu grau mínimo, pois se reconheceu que a quantidade de droga apreendida, bem como sua natureza, seriam fundamentos hábeis a aplicar a redução em seu patamar mínimo, ou seja, em 1/6. II - O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena discricionariedade para fixar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. Do contrário, seria inócua a previsão legal de um patamar mínimo e um máximo. III - A pena imposta ao paciente pela prática do crime de tráfico não desbordou dos lindes da proporcionalidade e razoabilidade. IV - Ordem denegada. (STF - HC: 106611 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 15/02/2011, Primeira Turma,

Data de Publicação: DJe-042 DIVULG 02-03-2011 PUBLIC 03-03-2011)

Destarte, de tudo o que foi exposto, tem-se que o acervo probatório é vasto e suficiente para ensejar a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas, restando comprovada a autoria e a materialidade, assim como a tipicidade delitiva, posto que não se fazem presentes causas excludentes de ilicitude, ao mesmo tempo em que o réu era plenamente imputável e lhe era exigido que agisse de forma diversa. Passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no art. 68 do Código Penal.

No que diz respeito à culpabilidade, que deve ser entendida como a capacidade do autor de perceber os fatos e de se determinar de acordo com eles e a reprovação social que sua conduta merece, não há elementos suficientes a se valorar. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, sempre observando o princípio da não-culpabilidade, conforme é consagrado pela jurisprudência pátria. Na espécie, o réu é primário. No que diz respeito à conduta social, "deve ser valorada pelo desempenho do réu na sociedade, na família e no trabalho, e não em relação aos fatos criminosos e atos infracionais supostamente cometidos, ou comprovadamente perpetrados, os quais devem ser apreciados, quando cabível, na avaliação dos antecedentes" (TJPR - 2ª C. Criminal - AC - 1360784-6 - Francisco Beltrão - Rel.: José Mauricio Pinto de Almeida - Unânime - J. 25.06.2015), não há elementos nos autos para valoração dessa circunstância. Na análise do vetor circunstâncias, previsto no art. 59 do Código Penal, deve ser apreciado o disposto no art. 42 da Lei de Drogas: Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na espécie, a quantidade e a natureza da droga apreendida não ensejam aumento da pena. Os motivos são inerentes ao próprio tipo violado, porquanto o agente, em tal conduta, visa o desejo de obtenção de lucro fácil. As consequências do ilícito são gravíssimas, em razão da má repercussão e da influência nefasta que esta modalidade delituosa exerce, especialmente, sobre os adolescentes, com resultados desastrosos nos núcleos familiares, com sua desestruturação e/ou muitas vezes, com sua destruição. A droga é causa de morte prematura de muitas pessoas em todo o mundo, de forma que tal espécie de crime merece pronto e eficaz combate da sociedade, mediante reprimenda exemplar para coibir sua prática. Entretanto, tais argumentos já foram considerados pelo legislador penal quando da elaboração do preceito secundário. Não há informações suficientes nos autos para valoração da personalidade do agente. Por fim, não que se há falar em comportamento da vítima, uma vez que se trata de crime vago. Assim sendo, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, não há agravantes a serem aplicadas; em contrapartida, incidem as atenuantes da confissão espontânea, ainda que tenha havido retratação posterior (art. 65, inciso III, "d", do Código Penal), e da menoridade relativa, uma vez que o réu era menor de 21 anos de idade na data dos fatos (art. 65, inciso I, do Código Penal). Contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que nesta fase é vedada a diminuição da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ, de modo que mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não incide qualquer causa de aumento de pena; por outro lado, deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Assim, nos termos da fundamentação, reduzo a pena em 1/2, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa.

Fixo cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos, em virtude dos poucos recursos financeiros do acusado (art. 49, § 1º, do CP e 43 da Lei nº 11.343/2006).

Como é cediço, para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do

Código Penal e eventual reincidência (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). Aliado a isso, o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Considerando a primariedade do réu e a quantidade de pena imposta, além de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais, fixo o REGIME ABERTO (art. 33, § 2º, "c", da Lei nº 11.343/2006), devendo ser observadas as seguintes condições (art. 115 da Lei de Execuções Penais): a) apresentar-se mensalmente em Juízo, para dar contas de suas atividades; b) manter trabalho lícito por todo o período e cumprimento da pena; c) não se ausentar do local de sua residência, por mais de 07 (sete) dias, sem prévia comunicação ao Juízo; d) recolher-se diariamente em sua residência no período compreendido entre 22h e 05h, assim como nos sábados, domingos e feriados; e) não portar armas ou instrumentos que possam ofender; f) não frequentar bares, boates, casas de prostituição ou quaisquer outros estabelecimentos afins, em qualquer horário do dia.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em entidade a ser indicada pelo Juízo da execução; e, b) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, em favor de entidade assistencial a ser indicada pelo Juízo da execução.

Com a substituição acima realizada, resta prejudicado o "sursis".

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu JOÃO PEDRO GIACOMELLI, brasileiro, solteiro, RG nº 55736726 SSP/SP, CPF 444.595.598-11, nascido em 27/07/2000, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Antônio Fernando Giacomelli e de Sandra Regina Santos Giacomelli, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do mínimo legal vigente na data dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em a) prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em entidade a ser indicada pelo Juízo da execução; e, b) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, em favor de entidade assistencial a ser indicada pelo Juízo da execução.

Quanto ao dinheiro (R\$ 63,00) e aos celulares apreendidos, em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do FUNAD, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 647 da repercussão geral, por maioria, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE 638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17/05/2017).

A Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias.

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos e valores apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e, tendo em vista que o sentenciado não se desincumbiu do seu ônus, decreto o perdimento do valor e dos celulares, a serem revertidos ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

Determino, ainda, a destruição das amostras da droga apreendida, mediante certificação nos autos (artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 525 das NSGJ).

Quanto ao às embalagens plásticas também apreendidas, por não possuir valor

econômico, determino a destruição.

Não há danos a serem reparados, motivo pelo qual deixo de fixar valor mínimo para indenização (art. 387, IV, CPP).

Condene o réu, também, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal; contudo, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade das custas, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.

Expeça-se certidão ao advogado nomeado à fl. 156, nos termos do convênio OAB/DPE, constando os atos praticados.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se carta de guia; b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, com a devida identificação do réu, acompanhada de fotocópia da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral c/c 15, inciso III, da Constituição Federal; c) oficie-se o Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; d) oficie-se à SENAD, para fins do disposto no artigo 63, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e) expeça-se certidão de sentença para execução da pena de multa e abra-se vista ao Ministério Público; e, a seguir, f) archive-se o processo, lançando a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação".

Publique-se. Intimem-se. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Pirapozinho, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA